

1510403-80.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510403-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510403-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119217/2022 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 24699177 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2119217 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISON ALTINO GONÇALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

EVERTON BASAGLIA DE LIMA e GLEISON ALTINO GONÇALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput, art. 34 e art. 35, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de maio de 2022, por volta de 16h15min, na Estrada Ecoturística de Parelheiros, 2800, Jardim Casa Grande, nesta Capital, previamente ajustados e com identidade de propósitos, guardavam, tinham em depósito, transportavam e ocultavam, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 1 saco de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha" (11kg); 1 saco de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha" (800g); 5 tijolos de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha" (1.810g), 450 porções de

cocaína (580g); 1 saco plástico contendo de cocaína (2.600g), um saco de cocaína (6.850g), 4.290 porções de cocaína (3.650g); substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

E ainda, porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local, utilizavam, possuíam e guardavam, maquinário/aparelho/instrumento, destinados à fabricação, preparação e produção de drogas, especificamente uma máquina empacotadora automática de sachês, uma máquina picotadora, uma prensa, 15 eppendorfs vazios, uma mala e quatro balanças com resquícios de drogas, 2 funis com resquícios de drogas, além de 7 rolos de filme plástico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput, e parágrafo 1.º, e 34, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, os denunciados se associaram para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes - mediante prévio ajuste e divisão de tarefas para consecução da empreitada espúria. Para tanto, dirigiram-se ao local dos fatos e, com a utilização de instrumentos e objetos, reuniram-se e promoveram a divisão/produção e o acondicionamento das drogas acima mencionadas.

Nas circunstâncias de tempo e lugar referidas, policiais civis da equipe Falcão 22 - 2ª Delegacia da DISE/DENARC - receberam informação privilegiada sobre indivíduos envolvidos com tráfico de drogas nas proximidades da Estrada do Porto, extremo sul da capital.

Diante disso, os policiais civis para lá se dirigiam, com o fim de apurar a veracidade da informação, circunstâncias em que avistaram uma chácara, situada na Rua 04 do bairro Vila Nova, em Parelheiros, e suspeitaram que ali haveria a fabricação/distribuição de drogas.

Durante campanha, observaram dois veículos, um Fiat/Idea, placas OUE8G94, e um Kia/Sportage, placas EQH5338; após a saída de ambos, na Estrada Ecoturística de Parelheiros, abordaram os condutores/denunciados.

Realizada busca nos veículos, nada de ilícito foi encontrado no Kia/Sportage; no entanto, no interior do Fiat/Idea, em compartimento oculto, encontraram 450 eppendorfs com cocaína.

Em buscas na mencionada chácara, os policiais encontraram uma máquina empacotadora de sachês; uma máquina picadora/trituradora; uma prensa; rolos de filme plástico, utilizados na empacotadora; dois rolos ostentando a imagem de um ator; um rolo ostentando a imagem de um jogador de futebol; eppendorfs; potes plásticos vazios; quatro balanças; um funil, um balde, uma mala de cor vermelha; uma arma de fogo artesanal, sem marca de fabricação, calibre 12 (inapta à realização de disparos, conforme laudo de fls.129/133), dois carregadores de munição, em péssimo estado de conservação (laudo de fls. 134/137) e duas placas de identificação veicular.

Ainda durante a vistoria no local, os policiais localizaram vultosa quantidade de maconha, a granel e prensada (1 tijolo e 4 pedaços), dois (2) sacos contendo cocaína, e 4290 (quatro mil, duzentos e noventa) invólucros plásticos, já prontos para a venda, contendo cocaína.

Os réus foram presos em flagrante, sendo decretadas as suas prisões preventivas em decisão de fls. 97/103.

Pela celeridade processual, foi convertido o rito procedimental em ordinário e recebida denúncia em 30 de maio de 2022 (fls. 179/181). Na mesma ocasião, foi determinado o arquivamento do inquérito somente em relação ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Os réus foram citados, foi apresentada resposta à acusação (fls. 232/233) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 237).

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas comuns e, após, os réus foram interrogados.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A Defesa dos acusados, por seu turno, postulou a absolvição dos acusados, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente,

postulou a fixação da pena-base no mínimo legal para GLEISON, concessão a ele do benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Com relação a EVERTON disse que é primário com relação a delito da lei de drogas, fixação da pena no mínimo legal, concessão a ele do benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, regime inicial menos gravoso.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva surge do auto de exibição e apreensão de fls. 38/40, do Boletim de Ocorrência de fls. 16/23, da prova oral coligida nos autos, bem como dos laudos periciais de fls. fls. 29/37 (constatação), fls. 208/211 (entorpecentes); fls. 212/214 (tritador e empacotadora com resquícios de entorpecentes); fls. 138/141 (veículo com compartimento oculto no painel); fls. 142/148 (ependorfs e microtubos) e fls. 197/204 (fitas plásticas).

As substâncias apreendidas (fls. 39) com os acusados foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para COCAÍNA e TETRAHIDROCANABINOL (THC), listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 208/211), corroborando o auto de constatação de fls. 29/37.

Provada, portanto, a materialidade delitiva do tráfico.

A autoria também restou incontroversa.

Na fase inquisitiva, os réus optaram por permanecer silentes (fls. 07 e 11)

Em Juízo, EVERTON, como esperado, negou a prática dos delitos. Foi pagar uma adega, encontrou "um cara que morava lá perto", "Cristian", ele fez proposta de "carregar droga" que não tinha risco de ser preso. Havia um carro vermelho olhando para eles. Foi para sua casa. No outro dia, foi à padaria e "Cristian" estava lá de novo.

Falou de novo para ele trabalhar com ele. Negou. Saiu e viu de novo o carro vermelho. Na segunda-feira, GLEISON foi até sua casa porque iam jogar bola. Foi ao mercado que tem na rua da sua casa. GLEISON foi com ele. O carro vermelho veio e falaram "perdeu, perdeu" e os policiais lhes algemaram e os levaram ao "mato". lá eles abordaram o portão, e lá tinha dois carros, os dois sujos, parecia que estavam há algum tempo. Dentro do local tinha muita droga, e se ele desse "o Cristian" iriam soltá-lo. Não sabe se o local era de "Cristian", apelido "Da Sul". Não estava conduzindo o carro Idea. Não conhecia os policiais e não sabe por que o estão incriminando. Foi levado para averiguação, e foi preso.

Já GLEISON, da mesma forma, negou a prática dos delitos. Foi à casa de EVERTON para falar de futebol, ele o chamou para ir ao mercado, foram, ficou esperando na porta, quando estavam indo embora, veio um carro vermelho, eram os policiais. Veio uma viatura, e os policiais o levaram a uma casa no meio do mato. EVERTON foi levado para dentro da casa. Voltaram e disseram que tinham encontrado drogas. Não estava dirigindo carro, não sabe de chave da chácara.

A versão dos acusados, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a eles incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito. A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação, nos termos da denúncia.

O Policial Civil Adalberto Barbosa reconhecendo os réus em audiência, disse que efetuaram diligências, após informações, por ordem de serviço, passaram a monitorar a chácara e no terceiro ou quarto dia localizaram dois carros na chácara. A notícia indicava o endereço, "no final de uma rua sem saída em uma área rural", mas não nomes das pessoas. Eram um Sportage e um Idea. Eles saíram, primeiro o Idea, abordaram os dois carros. Localizaram droga no Idea, em um compartimento secreto, que abria por alguns botões e abria o "cofre", tinham 400 e poucas porções de cocaína. No outro carro não encontraram nada de ilícito. EVERTON conduzia o Idea. Ele disse que só tinha ido buscar. Foram até a chácara, tinha cocaína por toda parte, na cozinha ficava a máquina de empacotar, no quarto, na sala. A casa não era habitada. Não tinha ninguém lá. Não havia outros carros estacionados. A empacotadora não estava funcionando. Tinha uma trituradora ao lado. Tinha imagens de Fabio Assunção e Maradona nas embalagens, havia também uma arma velha, sem condições de uso. Não conhecia os acusados. Havia muita droga dentro da casa. Não viram outra movimentação além dos réus no local. A chave da chácara estava dentro

da Sportage que era conduzida por GLEISON. Só viram nenhum dos acusados no local nos dias anteriores, eles foram lá só no dia da prisão, não viram outras pessoas entrando no local nos dias anteriores.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Civil Marcos Antonio Torres, que também reconheceu os réus em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é enorme e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos (cf. fls. 39 e fls. 209/210) – segundo o laudo pericial - 20,3kg de Tetrahydrocannabinol; 95,9g de cocaína; e 2,7kg de cocaína, bem como 2,4kg substância não identificada e 6,7kg de cafeína, sendo capazes de produzir cerca de 72.500 cigarros de “maconha” e cerca de 27.959 fileiras de cocaína e assim, suficientes para o comprometimento de um número ENORME de usuários.

Ademais, foram apreendidas balanças, peneira, mala, máquinas empacotadora e trituradoras com resquícios de entorpecentes (fls. 32 e 213), bem como automóvel com compartimento oculto no painel (fls. 138/141).

Assim, tudo nestes autos revela que os réus tinham em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de “atos de cogitação e preparatórios”. Neste sentido:

“TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou “traditio” - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência”(…)(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

“TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J.

Outrossim, também restou configurado o delito previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06, vez que comprovado que os acusados possuíam e guardavam, maquinário/aparelho/instrumento, destinados à fabricação, preparação e produção de drogas, especificamente uma máquina empacotadora automática de sachês, uma máquina picotadora, uma prensa, 15 eppendorfs vazios, uma mala e quatro balanças com resquícios de drogas, 2 funis com resquícios de drogas, além de 7 rolos de filme plástico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidas, bem como as condições da prisão, é possível a condenação dos acusados também pelo crime do art. 35 da Lei de Tóxicos, havendo indicação de associação estável para a prática do delito de tráfico de drogas, bem como a divisão de tarefas entre os acusados. A propósito, cumpre ressaltar que o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06: "Trata-se de crime autônomo, isto é, a sua caracterização não depende da prática de qualquer dos crimes referidos no tipo, os quais, em ocorrendo, configurará concurso material de delitos (art. 69 do CP). Assim já decidiu o STF: 'É perfeitamente possível que ocorra concurso material entre tráfico de entorpecentes e associação estável, pois o crime autônomo, previsto no art. 14 da Lei 6.368/76 (atual art. 35), tem como finalidade cometer delitos dos arts. 12 e 13 da mesma lei (hoje, arts. 33, caput, e 34, respectivamente' (RT 773/503)". (Luiz Flávio Gomes, "Nova Lei de Drogas Comentada", Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pgs. 170/171). Inafastável, assim, a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar aos réus a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

1) O réu GLEISON é tecnicamente primário e responde por outro processo (fls. 85). A quantidade de drogas apreendidas é imensa - De fato, foram apreendidos (cf. fls. 39 e fls. 209/210) - segundo o laudo pericial - 20,3kg de Tetrahydrocannabinol; 95,9g de cocaína; e 2,7kg de cocaína, bem como 2,4kg substância não identificada e 6,7kg de cafeína, sendo capazes de produzir cerca de 72.500 cigarros de "maconha" e cerca de 27.959 fileiras de cocaína e assim, suficientes para o comprometimento de um número ENORME de usuários - tendo um potencial lesivo muito maior em razão da quantidade, pelo que atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base do delito de tráfico de drogas acima do mínimo legal em sete anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, com relação ao crime de tráfico de drogas.

Não verificando causas de aumento da pena-base, fixo-as em três anos de reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa, para o crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06 e em três anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, para o crime previsto no art. 35 da lei nº 11.343/06, todos utilizando o valor unitário mínimo. Não há atenuantes nem agravantes a serem consideradas.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a quantidade de droga apreendida - De fato, foram apreendidos (cf. fls. 39 e fls. 209/210) - segundo o laudo pericial - 20,3kg de Tetrahydrocannabinol; 95,9g de cocaína; e 2,7kg de cocaína, bem como 2,4kg substância não identificada e 6,7kg de cafeína, sendo capazes de produzir cerca de 72.500 cigarros de "maconha" e cerca de 27.959 fileiras de cocaína e assim, suficientes para o comprometimento de um número ENORME de usuários - obsta o reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. "Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução." (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Ainda, há o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, no sentido de que a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito:

"Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado ("lex mitior"), porque meramente facultativa a situação ("...as penas poderão ser reduzidas..." g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

No mesmo sentido:

"A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de "não se dedicar às atividades criminosas" (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente..." (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0102986-91.2014.8.26.0050. R. Des. Geraldo Wohlers. J. 10.11.2015). destaquei.

Pelo concurso material de crimes, somo as penas impostas, totalizando treze anos de reclusão e pagamento de 2.600 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

2) O réu EVERTON é reincidente e responde por outro processo (fls. 83/84).

A quantidade de drogas apreendidas é imensa - De fato, foram apreendidos (cf. fls. 39 e fls. 209/210) - segundo o laudo pericial - 20,3kg de Tetrahydrocannabinol; 95,9g de cocaína; e 2,7kg de cocaína, bem como 2,4kg substância não identificada e 6,7kg de cafeína, sendo capazes de produzir cerca de 72.500 cigarros de "maconha" e cerca de 27.959 fileiras de cocaína e assim, suficientes para o comprometimento de um número ENORME de usuários - tendo um potencial lesivo muito maior em razão da quantidade, pelo que atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base do delito de tráfico de drogas acima do mínimo legal em sete anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, com relação ao crime de tráfico de drogas.

Não verificando causas de aumento da pena-base, fixo-as em três anos de reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa, para o crime previsto no art. 34 da lei n.º

11.343/06 e em três anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, para o crime previsto no art. 35 da lei n.º 11.343/06, todos utilizando o valor unitário mínimo. Não há atenuantes a serem consideradas.

Pela reincidência, exaspero suas penas em 1/6, culminando em oito anos e dois meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa, com relação ao crime de tráfico de drogas; em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 1.400 dias-multa, para o crime previsto no art. 34 da lei n.º 11.343/06 e em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa, para o crime previsto no art. 35 da lei n.º

11.343/06, todos utilizando o valor unitário mínimo.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a reincidência do acusado, sendo que a lei não exige que seja específica, e a quantidade e diversidade de drogas apreendidas – De fato, foram apreendidos (cf. fls. 39 e fls. 209/210) – segundo o laudo pericial – 20,3kg de Tetrahidrocannabinol; 95,9g de cocaína; e 2,7kg de cocaína, bem como 2,4kg substância não identificada e 6,7kg de cafeína, sendo capazes de produzir cerca de 72.500 cigarros de “maconha” e cerca de 27.959 fileiras de cocaína e assim, suficientes para o comprometimento de um número ENORME de usuários – obstam o reconhecimento do redutor, vez que indicam que o acusado se dedica a atividades criminosas, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. “Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.” (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Ainda, há o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, no sentido de que a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito: “Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado (“lex mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

No mesmo sentido:

“A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...” (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0102986-91.2014.8.26.0050. R. Des. Geraldo Wohlers. J. 10.11.2015). destaquei.

Insta salientar, nesse ponto, que a valoração da reincidência na segunda fase da dosimetria, bem como nesta última para afastar o citado redutor não configura bis in idem. Nesse sentido, cito o trecho do voto do Desembargador Sergio Coelho: “não há qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia ou do ne bis in idem na utilização da recidiva como agravante genérica e, ao mesmo tempo, para afastar a causa especial de diminuição de pena, por se tratar de fases

distintas da dosimetria e gerarem efeitos diversos. Confirma-se, a respeito, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: (...) Não há que se falar em bis in idem quando considerada a reincidência na segunda etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase de aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação da reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e à reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido. (HC nº 178.933/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma". (TJSP; Apelação 0000218-53.2017.8.26.0577; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).

Pelo concurso material de crimes, somo as penas impostas, totalizando quinze anos e dois meses de reclusão e pagamento de 3.032 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR os réus:

1) GLEISON ALTINO GONÇALVES, como incurso nas penas dos arts. 33, caput, art. 34 e art. 35, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena total de treze anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 2600 dias-multa, com unidade no mínimo legal; e

2) EVERTON BASAGLIA DE LIMA, como incurso nas penas dos arts. 33, caput, art. 34 e art. 35, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena total de quinze anos e dois meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 3032 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Os réus não fazem jus a qualquer benefício, considerando as penas aplicadas e a hediondez do delito pelo qual foram condenados, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista as penas aplicadas, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei, bem como considerando a grande quantidade de drogas apreendidas. Neste sentido:

"Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dê que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar

entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

E ainda:

O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos. O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais. Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas. Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave. Mas há os considerados hediondos. Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável. Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado? O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo. A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social. O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados. Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminoso, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destruir outras sociedades, outras inúmeras famílias. Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa. O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal como procedeu o Legislativo. Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é absolutamente inadmissível. Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive! O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de que se trata de crime gravíssimo. Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Em liberdade, ou mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0084044-40.2016.8.26.0050, Relator Desembargador Poças Leitão, São Paulo, negaram provimento, v.u., j. 30/11/2017 - grifei).

E mais, a reincidência do acusado EVERTON e esta nova condenação indicam nenhum

regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

“tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal” (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

“Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

“Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário dos acusados para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar dos réus, ante a manifesta periculosidade que apresentam, a reincidência do réu EVERTON, bem como inalterada a situação fática que determinou a decretação de suas prisões anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar os acusados, ordenar a libertação deles, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomendem-se os réus no local em que se encontram presos.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA